刑法13 筆記：共謀共同正犯與特殊問題

來源：刑法13 課程字幕 02:10:00 ~ 02:39:00

🕮 法條原文速查

§28（共同正犯）
二人以上共同**實行**犯罪之行為者，皆為正犯。
→ 94年修法將「實施」改為「實行」，排除陰謀預備階段的共同正犯

§271（殺人罪）
I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

§302（私行拘禁罪）
I：私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處五年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

§328（強盜罪）
I：意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。

釋字/實務見解速查

釋字 109 號
以自己共同犯罪意思，參與實施構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，均為**共同正犯**。
→ 前段＝構成要件以外行為（如開車接應）；後段＝共謀共同正犯

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「全體均在預備階段，可否成立共同正犯？」	**不可以**（§28「實行」＝須有人著手）
「共謀者行為當下不在場，可否為共同正犯？」	實務（釋字109）：**可以**；嚴格說：**否定**（頂多教唆犯）；溫和說：**有條件承認**
「嚴格犯罪支配論的最低限度？」	行為當下用**通訊方式即時掌握現場**才可能論共正
「溫和犯罪支配論承認共謀共正的條件？」	共謀者須為**核心首腦**，共同行作犯罪計畫或組織犯行
「過失犯可否成立共同正犯？」	傳統：**不可以**；新說：**可以**（法條未明禁＋可解決因果不明問題）
「擇一共同正犯中事後無用的人，是否共正？」	許恆達：**否**（事後無貢獻者非共正，但可論精神幫助犯）；德國多數說：**是**
「為殺人而先壓制被害人（§302），如何處理？」	§302 被殺人罪**吸收**，不另論

一、過失的共同正犯

問題提出：瑞士滾石案

事實：甲乙在山坡上推大石頭，路人被其中一顆砸死，無法查明是甲推的還是乙推的。

學說爭議

```
過失可否成立共同正犯？
│
├── 傳統說（否定）
│     └── 共同正犯需犯意聯絡 → 過失不可能犯意聯絡
│           → 批評：只回答問題的表面，沒回答本質
│                 （支持者可以說：把犯意聯絡要件換掉就好了）
│
└── 新說（肯定，越來越多學者支持）
      ├── 理由①：法條沒有明確反對（§28 只說「二人以上共同」，沒說故意或過失）
      └── 理由②：承認有實益
            └── 交互歸責 = 罪疑惟輕的例外
                  → 多人過失造成結果但不能證明是誰
                  → 肯認過失共同正犯 → 全體一起負責
```

實益示範：瑞士滾石案的結論差異

採否定說	採肯定說
甲：你沒證據證明是我推的 → 罪疑惟輕 → 無罪	甲乙為共同體 → 交互歸責
乙：你沒證據證明是我推的 → 罪疑惟輕 → 無罪	→ 全體為結果負責
結果：兩人都無罪（不合理）	**結果：兩人均有罪**

二、行為分擔

三種行為分擔的模式

```
共同正犯的行為分擔
│
├── ① 全體都做構成要件行為
│     └── 如：甲乙各持刀砍被害人
│
├── ② 有人做構成要件行為＋有人做構成要件以外行為
│     └── 如：甲架住被害人（非構成要件）、乙持刀刺（構成要件）
│
└── ③ 每人都只做部分構成要件行為
      └── 如搶銀行：
            甲開車接應（非構成要件）
            乙持槍威嚇（只有強制）
            丙跳入櫃檯取財（只有竊取）
            → 無人完整做 §328，但全體為共同正犯
```

結論：行為分擔**不要求**每人都做完整的構成要件行為。

三、陰謀與預備的共同正犯

結論：不能成立

法律依據：§28 修法將「實施」改為「**實行**」

```
§28 的「實行」
│
├── 實行 = 著手的同義詞（有著手才有實行）
│
└── 效果：排除全體均在陰謀或預備階段的共同正犯
      ├── 修法前（寫「實施」）→ 全體陰謀/預備可以成立共正
      └── 修法後（寫「實行」）→ 至少要有一人著手
```

四、共謀共同正犯

問題提出

共謀者＝有犯意聯絡、甚至是核心首腦，但**行為當下不在場**、沒有行為分擔。

案例

- 甲乙丙丁相約搶銀行

- 甲負責計畫安排人力
- 乙開車接應、丙丁去銀行行搶
- 行搶當天，**甲在家中睡覺**
- 甲 = 共謀共同正犯？

三說比較

學說	立場	說明
實務（釋字109）	無條件肯定	事前同謀＋其中一部分人實行 → 均為共正
嚴格犯罪支配論	否定（除非以通訊即時掌握現場）	不在場 → 不可能支配犯罪 → 頂多教唆犯
溫和犯罪支配論	有條件承認	共謀者須為**核心首腦**（共同行作犯罪計畫/組織犯行）

釋字 109 號的兩段

```
釋字 109 號
│
├── 前段：以自己共同犯罪意思，參與構成要件以外行為
│     └── 例：開車接應的乙（有到場，只是做構成要件外行為）
│     └── 這「不是」共謀共同正犯
│
└── 後段：以自己共同犯罪意思，事前同謀，由一部分人實行
      └── 例：甲在家睡覺
      └── 這才是共謀共同正犯的定義
```

三說的實際差異

案例：小弟阿悟

- 阿悟是強盜集團新人
- 行前會議都有參加，但沒提出建設性意見
- 搶劫當天也在家睡覺
- 事後參與分贓

學說	阿悟是否為共同正犯？
實務	**是**（無條件承認共謀共正）
溫和犯罪支配論	**否**（阿悟非核心人物，未達共同行作犯罪計畫/組織犯行）
嚴格犯罪支配論	**否**（當下不在場也沒通訊掌握）

→ 嚴格說對行為人最有利

五、擇一共同正犯

問題提出

事實：

- 甲乙要殺A
- A的豪宅有前門、後門
- 甲埋伏前門、乙埋伏後門
- A從後門離家 → **乙殺死A**
- 甲完全沒用（事後證明）

→ 甲還是共同正犯嗎？

學說爭議

學說	結論	理由
假說（推論實務見解）	肯定	實務連共謀共正（無行為分擔）都無條件肯定，擇一共正（有分擔但事後無效）更不可能否定
許恆達（乙說）	否定	行為分擔應從**事後**角度認定，事後無貢獻者 ≠ 行為分擔
德國多數說（丙說）	肯定	行為分擔包括「非典型貢獻」，只要**事前預期**有貢獻即可

許恆達老師的否定說補充

- 甲雖然不成立共同正犯
- 但甲埋伏前門讓乙更安心 → 甲可成立**精神幫助犯**
- 否定擇一共正 ≠ 全無刑責

六、考題演練：默示犯意聯絡與殺人共正

案例：圍毆致死案（警特四等）

事實：

1. 甲乙沒有事前溝通
2. 一前一後包夾被害人
3. 其中一人用雙手抓住被害人
4. 兩人拳打腳踢，被害人死亡

分析：

1. **犯意聯絡**：雖無明示，但動作眼神配合 → **默示犯意聯絡**
2. **私行拘禁（§302）**：甲乙包夾壓制 → §302 共同正犯
3. **殺人罪（§271）**：拳打腳踢致死 → 論§271 共同正犯
    - 為何不是傷害致死？→ 加重結果犯的共正是另一考點，警特四等不會考那麼難
4. **競合**：為殺人而壓制被害人 → §302 被§271 **吸收**，不另論
5. **結論**：甲乙論**殺人既遂罪的共同正犯**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§28	共同正犯（「實行」排除陰謀預備）	共謀共正、陰謀預備、擇一共正
§271	殺人罪	考題：殺人共正
§302	私行拘禁	考題：被殺人吸收
§328	強盜罪	共謀共正案例

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
釋字 109 號	事前同謀由部分人實行者，均為共同正犯（共謀共正之依據）

關鍵學說速查表

學者/理論	要旨
嚴格犯罪支配論	否定共謀共正（除非以通訊即時掌握現場）
溫和犯罪支配論	有條件承認（須為核心首腦）
許恆達	擇一共正否定說（行為分擔從事後判定；但可論精神幫助犯）
陳子平	共犯論權威，擇一共正概念早在其書上介紹